

1501237-23.2021.8.26.0660

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas, inclusive já foi preso por tráfico, ele ao perceber a nossa presença acelerou o passo, sendo abordado de frente a sua casa, em revista pessoal foi localizado consigo quatorze pinos de cocaína cheios e vinte reais em dinheiro, em uma nota só, ao ser entrevistado, o indiciado disse à equipe que seria usuário de drogas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Sentença nos autos sob o n. 1501237-23.2021.8.26.0660 - lauda de  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501237-23.2021.8.26.0660

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FAUSTINO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia GABRIEL FAUSTINO DA SILVA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que, na tarde de 16 de dezembro de 2021, por volta das 13 horas, na Rua São Pedro, altura do nº 203, Vila São Pedro, nesta cidade e comarca, ele trazia consigo, para fins de tráfico, 8,62 gramas de cocaína, acondicionados em 14 microtubos plásticos, tratando-se de substância que causa dependência física e química, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (f. 01/05) e teve a prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia (f. 44/48).

O acusado foi notificado (f. 98) e apresentou defesa preliminar (f. 119/120).

A denúncia foi recebida no dia 16 de março de 2022 pela decisão de fls. 121/123 e o réu foi citado (f. 142).

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas e, por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha WILLIANS JOÃO ALVES PRIMO, policial militar, ouvido na fase de inquérito (f. 02), declarou: "Em patrulhamento pela Rua São Pedro, avistamos o autor Gabriel transitando a pé pela referida rua e este conhecido nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas, inclusive já foi preso por tráfico, ele ao perceber a nossa presença acelerou o passo, sendo abordado de frente a sua casa, em revista pessoal foi localizado consigo quatorze pinos de cocaína cheios e vinte reais em dinheiro, em uma nota só, ao ser entrevistado, o indiciado disse à equipe que seria usuário de drogas e que havia comprado esses pinos de cocaína pelo valor de vinte e cinco reais cada e que iria ser consumido por ele e pelo amásio, não entrando mais em detalhes de quem havia comprado o entorpecente e local onde havia adquirido. Quanto ao dinheiro, o autor disse ser oriundo do seu trabalho como vendedor de roupa".

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e avistaram o acusado caminhando pela rua; ele acelerou o passo ao ver a viatura; ele é conhecido dos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas; já teve ocorrências enquanto adolescente; tudo isso chamou a atenção dos policiais; ele foi abordado pela via pública; em revista pessoal, encontraram 14 pinos de cocaína cheios e 20 reais em dinheiro; o acusado disse ser usuário de drogas e iria usar esses pinos com um parceiro; não entrou em detalhes sobre a origem dessa droga; disse que o dinheiro era oriundo de seu trabalho; a abordagem ocorreu na via público, chegando em frente à casa do acusado; isso foi durante o dia.

A testemunha RONALDO ADRIANO LOPES, policial militar, ouvido na fase investigativa (f. 03), afirmou: "Em patrulhamento, deparamos com o Gabriel em atitude suspeita que ao perceber a aproximação da viatura policial aumentou o passo, sendo abordado e em busca pessoal foi localizado quatorze pinos de cocaína e vinte reais em dinheiro no bolso da bermuda que trajava, perguntado para ele sobre a procedência da droga e do dinheiro, o autor disse que era usuário, que havia pago a quantia de vinte e cinco reais cada pino e sobre o dinheiro informou que era oriundo da venda de roupas".

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento por local em que já tiveram várias ocorrências de tráfico de drogas; encontraram o acusado em via pública e efetuaram a abordagem; foram encontrados com ele 14 pinos de cocaína e 20 reais em dinheiro; o acusado disse que o dinheiro era proveniente de seu trabalho e havia comprado a cocaína por 25 reais cada pino; a abordagem do acusado foi motivada porque ele acelerou o passo ao visualizar a viatura; o depoente não presenciou o acusado comercializando droga.

O acusado, ouvido em solo policial (f. 04), respondeu: "Eu estava chegando em casa,

retornando do supermercado, eu tinha comigo alguns pinos de cocaína para consumo meu, vi a viatura e acelerei o passo, sendo que fui abordado na frente da minha casa. A droga estava no bolso da minha bermuda, quatorze pinos, sendo que faço uso diário de quatro a seis pinos de cocaína por dia. O dinheiro que foi encontrado comigo era o troco do mercado e eu iria usá-la para consumir cocaína. Essa droga eu comprei em S. Paulo, em uma visita que fiz, de excursão, na região do Brás. Paguei a quantia de vinte e cinco reais o pino de cocaína. Eu não comercializo droga, era para uso próprio. Os policiais militares me trataram com respeito durante a abordagem, expliquei para eles que a droga era para o meu consumo. Os policiais militares, após encontrarem a droga comigo, entraram na minha casa para ver se havia mais droga, eu os autorizei”.

Em juízo, disse que, no dia do ocorrido, não foi abordado na rua de casa, mas dentro da sua casa; estava na companhia de seu namorado usando drogas; entraram dentro da sua casa; não havia mandado; o PM ADRIANO deu um tapa em sua cara; foi conduzido à Delegacia de Polícia; não foi apresentada droga alguma; foi apresentado apenas o dinheiro; o depoente disse que havia sete pinos em sua casa; consigo havia apenas sete pinos; há perseguição do PM ADRIANO; seu namorado não foi conduzido à Delegacia de Polícia; apenas o depoente lhe conduziu; o depoente não teve problema com esse policial; em relação ao depoimento em Delegacia de Polícia, diz ter sido ameaçado a contar essa versão; indagado sobre a audiência de custódia, afirma que nada disse sobre as agressões por orientação de seu advogado.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (f. 01), boletim de ocorrência policial (f. 06/07), auto de exibição e apreensão (f. 08), exame toxicológico provisório (f. 10/12), laudo de exame químico toxicológico definitivo (f. 94/96), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A prova testemunhal foi firme e coerente, está de acordo com o acervo documental e corrobora integralmente os fatos levados a conhecimento da autoridade policial, à vista do boletim de ocorrência lavrado.

O depoimento dos policiais militares deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado). Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre). Entretanto, no caso concreto, os policiais militares apresentaram versões firmes e coerentes entre si, cujas palavras não estão isoladas nos autos, mas, pelo contrário, respaldadas pelas demais provas. Ademais, não há notícia de conflito ou atrito entre acusado e policiais, seja prévio ou contemporâneo aos fatos. Por tais motivos, os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem elevado valor.

Não pode ser acolhida a tese defensiva de nulidade da apreensão por invasão de domicílio. De fato, a Constituição da República determina a inviolabilidade domiciliar no seu art. 5º, inciso XI; mas traz exceções, quais sejam a ocorrência de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603616 (Plenário, j. 05.11.2015), com reconhecida repercussão geral, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. No caso em apreço, não restou demonstrada a violação domiciliar, pois as provas coligidas não comprovaram que a apreensão se deu dentro da casa.

Vale observar que, em depoimento prestado em Delegacia de Polícia, o acusado admitiu que fora abordado na porta da sua casa, ainda em via pública, portando

consigo 14 pinos de cocaína.

Não convence a versão inédita apresentada em Juízo pelo acusado, explicando que fora abordado no interior da sua casa e fora ameaçado para contar a história em Delegacia de Polícia. A história é singela e incompatível com a gravidade da situação, que exigiria denúncia pronta e detalhada, especialmente na audiência especificamente designada para tal finalidade – audiência de custódia. Contudo, o acusado nada disse na oportunidade, sendo incoerente a alegação de que não o fez por orientação de seu advogado. Fosse verdadeira esta versão dos fatos, não seria esperado que o acusado aguardasse até esse momento para apresentar a denúncia. Ademais, não é crível que o acusado houvesse sido obrigado a apresentar uma versão que, embora diversa da agora deduzida, é igualmente exculpante em relação ao crime de tráfico de drogas. Houvesse ameaça, seria de se esperar que o algoz pretendesse obrigá-lo a narrar versão incriminatória.

Neste quadro, a versão de autodefesa do acusado ficou mesmo isolada, não encontra respaldo nos autos e não pode impedir a condenação.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, portava droga e não o fazia com o elemento subjetivo específico de consumi-la, o que fica especialmente demonstrado pela quantidade significativa de drogas. Vale lembrar que o acusado trazia consigo 14 microtubos de cocaína, o que parece, em um primeiro momento, exceder ao que uma pessoa, ainda que drogadicta, consumiria em um dia. Como o custodiado foi encontrado em via pública, era de se esperar, se apenas usuário fosse, que não tivesse consigo droga além daquela que fosse imediatamente usar.

Ressalte-se que o fato de não ter restado demonstrado a efetiva venda da droga não afasta a tipicidade do delito. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

A culpabilidade é normal à espécie. O sentenciado não registra maus antecedentes. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social do sentenciado. Não é possível aferir, quer em sentido técnico ou em sentido vulgar, a personalidade do sentenciado. O motivo da conduta não é especialmente censurável, não sendo insito ao crime e, portanto, já valorado pelo legislador no momento da criminalização primária. As circunstâncias são próprias do tipo penal, não sendo especialmente reprováveis. As consequências não são especialmente graves. Não há vítima específica e, portanto, o comportamento da vítima não é elemento aplicável ao delito em apreciação. Não estando a droga apreendida entre aquelas mais severamente lesivas à saúde pública, a natureza da droga não eleva a pena-base. Por fim, a quantidade de droga não excede à normalidade das apreensões nesta comarca. Não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, a pena permanece no valor mínimo legal, qual seja 5 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

O acusado é reincidente, inclusive específico, conforme certidões de f. 71-73, 74 e 75-77. O acusado tinha mais de 21 anos à época dos fatos. Portanto, agravo a pena e fixo a pena-provisória em 5 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 583 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime fechado.

Houve prisão cautelar no curso do processo. A segregação cautelar durou 0 ano(s), 4 mês(es) e 10 dia(s), de modo que resta cumprir uma pena privativa de liberdade correspondente a 5 ano(s), 5 mês(es) e 20 dia(s) de reclusão. O tempo de prisão processual é inferior ao lapso necessário para a primeira progressão de regime, o que não autoriza a aplicação do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e impõe a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena já fixado.

Indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o patamar da pena aplicada está além do determinado no art. 44 do Código Penal.

Não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal e, por esse motivo, indefiro a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o delito praticado não gerou dano material.

O(a) acusado(a) respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Portanto, mantenho a prisão preventiva.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado GABRIEL FAUSTINO DA SILVA, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de pena de multa no valor de 583 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

(a) Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

(b) Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos presentes autos, devendo a serventia providenciar ofícios pertinentes para que seja feita sua transferência ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º da Lei 11.343/06.

(c) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);  
(d) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;  
(e) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;  
(f) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;  
(g) Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Viradouro, 26 de abril de 2022.

PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA